

1502827-98.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1502827-98.2021.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502827-98.2021.8.26.0542

Controle: 2021/002082

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

LUAN LUIZ OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

LUAN LUIZ OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, em 5 de dezembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Eduardo Dias, 19, Jardim Roberto, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com outrem, não-identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em face de Ivanildo, uma motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, uma aliança de ouro e um aparelho telefone celular Xiaomi, a ele pertencentes.

Apurou-se que, na data do ocorrido, previamente ajustados entre eles, Luan Luiz e o indivíduo não-identificado, embarcados na motocicleta Honda XRE preta, sem placas, abordaram Ivanildo, que trafegava pelo local dos fatos em sua motocicleta. Exibindo arma de fogo, os roubadores anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram a motocicleta, a aliança e o aparelho telefone celular de Ivanildo, evadindo-se em seguida.

Todavia, horas depois, policiais militares, em patrulhamento pela Rua Caxias do Sul, em Osasco-SP, avistaram dois indivíduos mexendo em duas motocicletas, em circunstância suspeita, os quais empreenderam fuga ao perceberem a aproximação da

guarnição.

Luan Luiz foi alcançado e abordado, ao passo que seu comparsa logrou fugir sem ser identificado.

Em pesquisa ao chassi das motocicletas, constatou-se que eram produto de roubo.

Instado a comparecer ao Quinto D.P. Local, Ivanildo reconheceu Luan Luiz, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do delito que lhe vitimara.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 105/107) e citado Luan Luiz (fls. 116). Sobreveio a resposta escrita (fls. 120) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 121/122).

Em instrução processual criminal foi ouvida a vítima (fls. 147) e testemunhas (fls. 148/149), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 150).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 151).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Luan Luiz nos da denúncia (fls. 154/159).

A Defesa, por sua vez, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pelo afastamento dos §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, artigo 157, do Código Penal (fls. 168/183).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Preliminarmente, é de se declarar a nulidade do reconhecimento pessoal na fase policial.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua mais moderna jurisprudência, estabeleceu que o reconhecimento extrajudicial, seja pessoal ou fotográfico, que não observe os ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal, não serve de lastro para embasar a condenação, ainda que o reconhecimento seja confirmado judicialmente.

“Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar “falsas memórias”, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial (...) 8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido” (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 652.284-SC. Relator: Ministro Reynaldo

Soares da Fonseca. Julgamento: 27 de abril de 2021).

Ora, no caso destes autos, tem-se que a vítima Ivanildo relatou que no momento do delito viu as roupas do agente e parte do rosto dele, pelo capacete, que estava com a viseira aberta. Na Delegacia foi colocado apenas o acusado para reconhecimento e, quando lhe chamaram, disseram que localizaram uma pessoa que estava mexendo em sua motocicleta, que estava sendo desmontada. Portanto, não observadas as cautelas do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que não apresentada nenhuma outra pessoa para fins de reconhecimento, tornando esse ato extrajudicial nulo. Observe-se, ainda, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a inobservância das regras para fins de reconhecimento na fase policial macula o reconhecimento em Juízo, eivado de preconceção da imagem da pessoa a ser reconhecida.

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio

exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão – SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade

policial de investigação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.886-SC. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 13 de abril de 2021).

Assim sendo, com fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal DECLARO NULA a PROVA consistente em RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL e, por derivação, a PROVA do RECONHECIMENTO JUDICIAL (Supremo Tribunal Federal. R.H.C. 90.376. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento: 2 de abril de 2007).

No mais, materialidade delitiva se consubstancia em auto de prisão em flagrante delito (fls. 2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 13/15) e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 30 e 32), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 147/149) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria de (fls. 150).

Perante a D. Autoridade Policial, Luan Luiz negou a prática delitiva. Na hora e local dos fatos estava na entrada de um baile funk, na companhia de duas conhecidas, quando chegaram três indivíduos, montados em duas motocicletas. Dentre eles conhecia apenas Bruninho. Instantes após, chegou a Polícia Militar, momento em que os indivíduos se evadiram. Após os milicianos levantarem seus antecedentes, resolveram atribuir-lhe a posse das motos (fls. 9).

Em Juízo, confessou a prática delitiva. Declarou que os fatos começaram no dia anterior a sua prisão. Estava há um mês em Osasco e recebeu o convite para praticar o assalto. Atuou com o comparsa e abordaram a vítima. Não simularam que estavam armados e nem disseram que estavam armados, apenas pulou de sua moto e pegou a moto da vítima pedindo que entregasse aliança. Seu comparsa não estava com arma de fogo. Não falaram que iriam dar um tiro na vítima. Foi abordado no dia seguinte e estava com a moto mexendo com o kit de ferramentas no filtro da moto. Não estava desmontando a moto (fls. 150).

Inferir-se que a confissão representou idôneo liame entre a autoria e o evento perpetrado, encontrando-se corroborada pelas demais provas produzidas. Deve, pois, ser considerada sincera naquilo que está confortada pelas provas. Neste sentido: "Confissão Judicial - Ausência de circunstância que evidenciem insinceridade - Suficiência - Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa". (Ap. 470.903-2-SP - 8a C. - TACrim - j. 08.10.87 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida)

A vítima Ivanildo relatou que estava fazendo delivery na rua com sua moto quando um ônibus fez uma curva fechando a rua. Reduziu a moto para esperar. Os dois autores vieram em uma moto XR preta pela calçada e ficaram ao lado do declarante, sendo que um deles segurou seu braço e ordenou que descesse da moto. O outro, que estava pilotando, a todo momento dizia: Dá no peito dele, como se fosse para atirar. Eles pediram sua aliança e o seu celular estava no painel da moto. O piloto de novo gritava para dar um tiro no peito do declarante. Teve que entregar também a sua aliança.

Não viu arma de fogo. Enquanto o piloto se ajeitava se movimentando como se fosse tirar uma arma da cintura, o comparsa estava tirando algumas coisas da mão do declarante e com a outra na cintura. Recuperou a moto, mas não a aliança e o celular. Tinha seguro de sua moto e acionou o seguro. Sua moto foi localizada, mas estava em um local de difícil acesso onde havia um baile funk. Sua moto foi recuperada por volta das 23h. Foi a polícia que recuperou a moto. Fez reconhecimento na Delegacia (fls. 147).

A testemunha Policial Militar Anderson asseverou que a motocicleta produto de roubo já constava na planilha. Segundo o Copom., pelo rastreador ativo ela estava rodando no bairro Padroeira. Na Rua Caxias do Sul avistaram dois indivíduos que desmontavam duas motos sem placa. Um conseguiu fugir e Luan foi abordado. Em busca pessoal nada de ilícito foi apreendido com ele. Em consulta pelo chassi verificaram que as motos eram produtos de roubo. Conduziram o acusado até o 5º D.P. onde as vítimas compareceram. Uma delas reconheceu o acusado. A outra não.

Não conversaram com o acusado no local porque ali estava tendo um baile funk com quinhentas pessoas e elas foram para cima dos policiais. Conduziram Luan e as duas motos que estavam no local.

Além de Luan e o outro que fugiu não havia outras pessoas próximas das motos. O pancadão estava a 50m de distância aproximadamente. Ambos estavam com ferramentas e mexendo nas motos. As ferramentas eram de um kit que acompanha uma das motos. Não chegou a perguntar para o acusado o porquê estavam com as motos. Ninguém foi arrolado como testemunha até porque jogaram pedras. Não acompanhou o reconhecimento na Delegacia. Não se recorda das roupas que o acusado usava no dia. Não se recorda de apreensão de capacete (fls. 148).

A testemunha Policial Militar Adjanira afirmou que visualizaram dois rapazes mexendo em duas motos semelhantes, desmanchando-as. Um deles fugiu e Luan foi detido. As motos estavam sem emplacamento e pelo chassi verificaram que era produto de roubo. Luan foi conduzido ao D.P. e uma das vítimas reconheceu como sendo o autor do roubo.

Nas proximidades da moto apenas estavam o que fugiu e Luan. Havia um pancadão nas imediações. Após a abordagem essas pessoas do pancadão foram hostis e solicitaram apoio. Após a chegada do apoio conduziram ao D.P.. Havia uma maleta de ferramenta que estava sendo usada para desmontar as motos. Essa maleta vem no kit da motocicleta e foi apresentada na Delegacia. Não se recorda de apreensão de capacete. O acusado, indagado por que estava mexendo na moto, não quis dizer nada. Não presenciou o reconhecimento na Delegacia (fls. 149).

A autoria é, pois, indelegável, pois, se não bastasse ter Luan Luiz, judicialmente, confessado a prática delitiva, foi ele abordado mexendo na motocicleta subtraída de Ivanildo, junto com outra pessoa, que se evadiu:

“Nos delitos patrimoniais como o furto, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, de modo que aquela que se mostra dúbia e inverossímil transmuda a presunção da certeza, autorizando o desate condenatório” (Ap. no 646.631, 4ª Câ. - Rel. Juiz Passos Freitas, j. 27.07.93, V.U., rolo-flash 750/236).

Não há que se cogitar da existência da grave ameaça perpetrada pelo acusado. Isso porque a vítima narrou que foi abordada com um dos agentes segurando seu braço e ordenando que desembarcasse de sua motocicleta, sendo que o roubador que pilotava a outra motocicleta dizia para que desse um tiro em seu peito.

Tentativa, à evidência, não ocorreu. A questão do momento da consumação do crime de roubo hoje se encontra devidamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é necessária a posse tranquila da coisa roubada pelo roubador, operando-se a consumação quando detém a posse, ou seja, com a retirada da coisa que estava em poder da vítima com o emprego de grave ameaça ou violência, independentemente de locupletar-se ou não depois disso. Não é, pois, necessária a posse tranquila da res, fora da esfera de vigilância do dominus.

O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça. A rápida recuperação da coisa e a prisão dos agentes não caracteriza a tentativa (S.T.J. - R.E. 77.868 - SP - Rel. Min. Félix Fischer- J. 04.03.97- DJU 14.04.97). Tal é o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO (ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da res furtiva. Sendo desnecessário que a posse da coisa seja mansa e pacífica. Precedentes: RE 102.490, Relator o Ministro Moreira Alves (Pleno); HC 89.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma); HC 89.653, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 89.619, de minha relatoria (Primeira Turma). Por outra volta, não procedem as alegações de que houve reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ) e que não ficou demonstrada a divergência de interpretação, exigida pela alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF/88. Habeas corpus indeferido” (HC 89959, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007

PP-00070 EMENT VOL-02286-04 PP-00662 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 565-569).

Ademais, sequer todos os bens foram recuperados.

A execução delitiva foi perpetrada por dois agentes. Basta a pluralidade de pessoas, vale dizer, a concorrência de dois ou mais agentes.

Houve, portanto, divisão de tarefas durante a execução do crime e restou comprovado que o acusado e comparsa tinham a deliberada intenção de praticar o delito de roubo, configurando-se, pois, a causa de aumento do crime. Veja-se que Luan Luiz era o garupa na motocicleta e desembarcou abordando a vítima e dela tomando os bens, enquanto o outro ficou na condução, aguardando a subtração e, na sequência, evadiram-se juntos.

Relativamente ao § 2º-A, inciso I, artigo 157, do Código Penal, não restou demonstrado. Ivanildo, disse, mais de uma vez, não ter visto arma de fogo, sendo que nada lhe foi apontado e os agentes não fizeram menção de estarem armados, tendo a vítima relatado que um dos agentes ajeitava se movimentando como se fosse tirar uma arma da cintura, e Luan Luiz estava tirando algumas coisas de suas mãos e com a outra na cintura. Tem-se, portanto, que não exibida e nem visualizado armamento, e muito menos apreendido, não há que se falar na incidência desta causa de aumento. Não há qualquer viabilidade de desclassificação para o delito de furto. Do conjunto probatório amealhado aos autos, verificou-se a caracterização da grave ameaça quando da subtração. Tem-se que estes elementos tipificam o crime em tela, ou seja, o roubo, cuja característica fundamental é a redução da vítima à impossibilidade de resistir pelo caráter intimidativo da grave ameaça.

Conclui-se, pois, pela parcial procedência da ação penal, restando tipificado o delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O acusado não agiu com intensidade dolosa anormal para os delitos da espécie que justifique a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, conforme permissão do artigo 59, do Código Penal.

Luan Luiz faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Entretanto, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso judicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante

não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

Luan Luiz é reincidente, ex vi da informação trazida pela certidão criminal de fls. 141/142 dando conta de anterior condenação sem que tenha havido o transcurso do quinquênio depurador. Assim, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, a reprimenda será exasperada em 1/6.

O acréscimo de pena pelo concurso de agentes será de 1/3.

Considerando os elementos acima e os demais parâmetros contidos no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Deixo de agravar a reprimenda pela incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, compensando-o com a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não há outras atenuantes ou agravantes. Procedo, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao acréscimo de 1/3 em razão da causa de aumento especial prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, ou seja, a pena resulta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento 13 (treze) dias-multa. Não há outras causas de aumento ou de diminuição.

À míngua de qualquer outra causa legal de alteração, torno esta definitiva.

Para o condenado determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, coadunando-se com a natureza do crime, qual seja, roubo em concurso de agentes, praticado por reincidente, nos termos do artigo 33, § 1º, a, e § 3º, do Código Penal. Inaplicável, ainda, a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a reprimenda aplicada é superior a quatro anos, afastando, portanto, a incidência sumular.

É inaceitável a aplicação do regime mais brando. Isso porque o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa em concurso de agentes, por reincidente.

Ora, diante das circunstâncias acima evidenciadas pela grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade é incompatível.

Trata-se de delito que causa intranquilidade coletiva e de acentuada gravidade, como o roubo com causa de aumento de pena (concurso de agentes), praticado por reincidente. Pelas razões acima e pela quantidade de pena, sendo crime revestido de grave ameaça à pessoa, é inaplicável, ainda, a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO LUAN LUIZ OLIVEIRA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, por incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A prática do crime de roubo em concurso de agentes, cometido por reincidente, denota a periculosidade que é incompatível com a permanência do condenado em Sociedade, sendo necessária a segregação. A perturbação da Ordem Pública é evidente, gerando insegurança coletiva, além de desrespeitar os direitos primordiais da vítima, assegurados constitucionalmente. Encontram-se, pois, presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar e já elencados quando da decretação da prisão preventiva.

Assim sendo, nego ao apenado o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o sentenciado ao estabelecimento prisional onde se encontra preso em razão de sentença condenatória sem direito de apelar em liberdade. Expeça-se a guia de recolhimento provisória do condenado, fazendo, oportunamente, os devidos aditamentos.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que Luan Luiz está custodiado por este processo-crime desde 5 de dezembro de 2021 e, diante do quantum da reprimenda aplicada, ainda não faz jus à progressão de regime e/ou detração penal, que, tão-somente, serão levadas a efeito pelo Juízo das Execuções

Penais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 11 de março de 2022.